

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-1]취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 `폐기물 관리법` 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술하라.》

<문제2.1의 물음1> 취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사업장 폐쇄명령의 취소를 구하는 취소소송을 제기하고자 하고, 법원은 소송을 심리하는 과정에서 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지 등 소송요건의 구비 여부를 문제 삼고 있다. 쟁점으로 <취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질과 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위하여 직권으로 조사할 수 있는 사항의 원칙 및 예외>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술한다.

II. 취소소송 소송요건의 법적 성질

1. 소송의 적법요건

- 취소소송의 소송요건은 법원이 본안 심리에 들어가기 위해 반드시 갖추어야 할 전제조건이다. 이러한 소송요건을 갖추지 못한 소 제기는 부적법한 것이 되어 본안 판결(인용 또는 기각)을 내릴 수 없으며, 법원은 판결으로써 소를 각하해야 한다.

2. 재판상의 요건

- 소송요건은 소 제기 당시는 물론 변론 종결 시까지 계속해서 존재해야 한다. 만약, 소 제기 당시에는 요건을 갖추었더라도 소송 도중에 요건이 흠결되게 되면 법원은 소를 각하해야 한다. 반대로 소 제기 당시에는 흠결이 있었으나 각하되지 않고, 본안 심리가 진행되었다면 변론 종결 전까지 흠결이 치유되면 적법한 소가 된다.

3. 강행규정성

- 행정소송법상의 소송요건은 공익적 견지에서 정해진 강행규정이다. 따라서 당사자 사이의 합의로 소송요건의 흠결을 정당화하거나 면제할 수 없으며, 법원은 당사자의 주장 여부와 상관없이 이를 엄격히 심사해야 한다.

III. 직권조사 사항의 원칙과 예외

1. 직권조사의 원칙

(1) 의의

- 소송요건의 존부는 법원의 직권조사 사항에 해당한다. 이는 소송의 개시와 범위는 당사자의 의사에 맡기지만, 일단 개시된 소송이 적법한지 여부에 대한 판단은 사법 정의의 실현과 공익 보호를 위해 법원의 고유한 권한이자 의무로 보는 것이다.

(2) 법원의 의무

- 법원은 당사자가 소송요건의 흠결을 주장하지 않더라도 스스로 이를 조사하여 확인해야 할 의무가 있다. 만약, 피고인 행정청이 소송요건에 대해 아무런 이의를 제기하지 않더라도 법원은 대상적격이나 제소기간 등의 준수 여부를 독립적으로 심사해야 한다.

(3) 증명책임의 소재

- 소송요건의 구비 사실에 대한 증명책임은 원칙적으로 소를 제기한 원고에게 있다. 원고는 자신이 제기한 소가 적법함을 소명해야 하며, 법원이 직권으로 조사함에 있어 필요한 자료를 제출할 협조 의무를 진다.

2. 직권탐지주의의 예외적 적용

(1) 행정소송법 제26조와의 관계

- "행정소송법 제26조"는 법원이 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대해서도 판단할 수 있다"고 규정하고 있다. 이는 "민사소송법"상의 변론주의를 보완하여 행정처분의 적법성 확보라는 공익을 달성하기 위함이다.

(2) 직권조사와 직권탐지의 차이

- 직권조사는 판단의 기초가 되는 자료가 제출되어 있을 때 법원이 이를 스스로 검토하는 것을 의미하며, 직권탐지는 법원이 직접 증거를 수집하고 당사자가 주장하지 않은 사실까지 찾아내는 적극적인 행위를 포함한다. "판례"는 소송요건에 관하여 사실관계의 존부가 불분명한 경우 법원이 적극적으로 이를 탐지하여 확인할 수 있다는 태도를 취한다.

(3) 보정 명령

- 법원은 소송요건의 흠결이 발견되었으나 그것이 보정 가능한 성질의 것인 경우, 즉시 각하하기보다는 원고에게 보정을 명하여 국민의 재판청구권을 실효적으로 보장해야 한다. 예를 들어 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정 등을 유도하는 것이 이에 해당한다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송요건 검토

- 법원은 甲이 제기한 취소소송에서 A시장의 사업장 폐쇄 명령이 행정소송법상 처분에 해당하는지(대상적격), 甲이 해당 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지(원고적격), 그리고 제소기간 내에 소를 제기했는지 등을 직권으로 조사해야 한다.

2. 법원의 직권조사 수행

- 본 사안에서 법원은 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 가졌으므로, 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 관련 법령과 사실관계를 조사하여 대상적격 유무를 판단해야 한다. 만약, 사업장 폐쇄 명령이 폐기물 관리법에 근거한 구체적 사실에 대한 법집행으로서 공권력의 행사임이 확인된다면 처분성이 인정될 것이다.

V. 결론

- 취소소송의 소송요건은 소의 적법 여부를 결정하는 강행규정적 성격을 가지며, 법원의 직권조사 사항이다. 법원은 당사자의 항변 유무와 관계없이 소송요건의 구비 여부를 확인해야 하며, 필요시 직권으로 자료를 탐지할 수 있다. 甲의 소송에서 법원은 사업장 폐쇄 명령의 처분성을 직권으로 심사하여 소의 적법성을 먼저 가려낸 후 본안 심리에 임해야 한다. 이러한 법리는 행정소송이 단순히 개인의 이익 보호를 넘어 행정의 적법성 통제라는 공익적 기능을 수행하고 있음을 뒷받침한다.